

1500463-67.2022.8.26.0624

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CRIME DE MERA CONDUTA. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. GUARDA MUNICIPAL. ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA. ART. 301 DO CPP. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos delitos de mera conduta, aí incluídos o tráfico e a guarda de substância entorpecente, não é necessário resultado decorrente da ação ou omissão, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500463-67.2022.8.26.0624

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 3034310/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

MARCELA CRISTINA DE BRITO

Artigo da Denúncia:

Data da Audiência:

30/11/2022

Em 30 de novembro de 2022, às 13:30h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, na pessoa do DR. CARLOS EDUARDO POZZI, DD. Promotor de Justiça da Comarca de Tatuí, bem como o Defensor Técnico da ré, DR. Rudnei de Souza OAB 438846/SP. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual as testemunhas Renata Rosa Rodrigues Pinto (GCM) e Juceil Batista Rodrigues (GCM). INICIADOS OS TRABALHOS, pela MM^a Juíza foi dito: "Tendo em vista o não comparecimento da ré a esta solenidade, entretanto devidamente presente seu defensor constituído, DECRETO SUA REVELIA." Em seguida, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MM^a Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquirições fossem por elas iniciadas. Nada obstante o encerramento do Sistema Remoto de Trabalho e do Sistema Escalonado de Retorno ao Trabalho Presencial, a presente audiência foi realizada por meio de videoconferência, através da plataforma Microsoft Teams, conforme disciplina já estabelecida pela Corregedoria Geral da Justiça no Comunicado CG nº 284/2020 (cf. artigo 8º do Provimento CSM nº 2651/2022). Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo

individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. A ré MARCELA CRISTINA DE BRITO, devidamente qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, eis que, no dia 7 de maio de 2022, por volta das 19h07, na Rua Antônio Orlando Salmasi, nº 494 - Vila Vicente Correa, nesta cidade e Comarca de Tatuí, nas proximidades de uma sede de entidade recreativa (fls.42/43), trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 5 porções de "crack", subproduto da cocaína, com peso bruto aproximado de 1 grama, 7 porções de cocaína ("aricanduva"), com peso bruto aproximado de 5,8 gramas, e 29 porções de "crack", subproduto da cocaína, com peso bruto aproximado de 60,2 gramas,, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Narra a Denúncia que, na data dos fatos, a acusada estava exercendo o tráfico ilícito e, para tanto, trazia consigo algumas porções e permanecia no local da abordagem, que elegeu como "ponto", aguardando usuários para promover a venda oportuna. Na prática delitativa, MARCELA fazia uso de uma área de mata existente nas proximidades, local onde ela guardava e mantinha mais drogas em depósito, para posterior entrega ao consumo de terceiros. Guardas Civis estavam em serviço quando receberam informação de um popular dando conta de que MARCELA estava vendendo drogas "na viela", apontando suas características físicas e descrevendo suas vestes. Conforme a delação, a acusada trazia consigo algumas porções e escondia o restante das drogas numa área verde existente no lado oposto da rua, para onde se dirigia para pegar drogas conforme a demanda dos usuários. De imediato, os Guardas se dirigiam para o local indicado e, lá chegando, avistaram MARCELA que, por sua vez, escondeu drogas na boca quando percebeu a aproximação da viatura. Realizada a abordagem, a acusada entregou aos Guardas Civis 5 porções de "crack" que estavam dentro da sua boca, além da importância de R\$ 22,00 em espécie que trazia consigo, dinheiro angariado com a venda de entorpecentes que ela promovia naquele local. Verificando o local informado na delação, com o auxílio de cão farejador, os Guardas Municipais localizaram mais 29 porções de "crack" e 7 porções de cocaína ("aricanduva"), drogas que pertenciam a MARCELA e estavam destinadas à venda. Notificada pessoalmente, a ré apresentou Defesa Preliminar (fls. 90/91). Então, procedeu-se o regular recebimento da Denúncia em 07 de novembro de 2022 (fls. 93/95). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e decretada a revelia da acusada que não foi encontrada para ser citada mas constitui defensor nos autos (fls. 92) e deixou de comparecer ao ato de interrogatório. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação da acusada, nos exatos termos da Denúncia, enquanto a Defesa Técnica, de outro giro, postulou pela absolvição da ré, alegando insuficiência probatória, bem como, subsidiariamente, pela concessão de todos os benefícios legais cabíveis a incidir em fase de dosimetria da pena e fixação do regime prisional inicial. Certidão de antecedentes a fls. 27/29. É o relatório do necessário. Fundamento e Decido. Preliminarmente não há que se falar em nulidade no decreto de revelia ou ausência de citação da ré, eis que esta constitui advogado nos autos (fls. 92) que acompanhou a audiência, não havendo que se falar em prejuízo para defesa. Em matéria de nulidade rege o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade a ser declarada se o ato não causou prejuízo para defesa. Quanto a atuação da guarda civil municipal, também não vislumbro qualquer irregularidade. Faz-se necessário salientar que operação levada a cabo pelos agentes públicos em comento atendeu aos requisitos legais, não violando preceito constitucional ou abrigado em Lei. Ora, distintamente do alegado pelo D. Defensor, os guardas civis municipais, na data dos fatos, não estavam efetuando diligências para investigações preliminares, mas sim realizando patrulhamento rotineiro para prevenir e inibir ações criminosas contra o patrimônio público municipal, atribuição esta lhes conferida por lei ordinária (art. 5º, II, da Lei nº 13.022/2014), a qual regulamentou a competência atribuída em nossa Carta Magna a

esta corporação (art. 144, § 8º, da CF). E nesse patrulhamento rotineiro, encontraram um morador do bairro, fez uma denúncia apontando a pessoa da ré, que já era conhecido dos meios policiais, sendo esta identifica no local apontado e flagrada no momento em que colocara porções de entorpecente em sua boca. Proxima a ré ainda foram encontradas outras porções de entorpecentes. Como se vê, os guardas civis municipais não extrapolaram suas funções. Até porque, se presente o estado de flagrância delitiva, a atuação de "qualquer pessoa do povo" seria legal, de acordo com a previsão legal insculpida no art. 301 do Código de Processo Penal. Por tal razão, não há óbices para a ação dos guardas civis municipais, os quais, por serem agentes de segurança, não devem se manter inertes diante de patente atividade criminosa. Neste sentido, coleciono o seguinte julgado: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CRIME DE MERA CONDUTA. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. GUARDA MUNICIPAL. ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA. ART. 301 DO CPP. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos delitos de mera conduta, aí incluídos o tráfico e a guarda de substância entorpecente, não é necessário resultado decorrente da ação ou omissão, bastando a simples conduta para a constituição do elemento material da figura típica penal, o que afasta a dúvida sobre o estado de flagrância delitiva do recorrente. 2. Dessa forma, à luz do art. 301 do CPP, "qualquer do povo" poderia ter efetuado sua prisão em flagrante, aí incluídos os agentes públicos da guarda municipal. 3. Afastada qualquer ilegalidade na custódia provisória decorrente de flagrante delito, afastado está o seu relaxamento. 4. Recurso a que se nega provimento. (STJ - RHC: 17645 SP 2005/0066036-6, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 06/09/2005, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 26/09/2005 p. 408) (grifos aditados). Acrescente-se que até mesmo o legislador ordinário acolheu este entendimento, pois no art. 5º, inciso XIII, da Lei nº 13.022/2014, atribuiu a Guarda Civil Municipal a competência de "garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas", consolidando o entendimento jurisprudencial acima exposto. Por fim, quanto a instauração de incidente de dependência toxicológica, embora tenha a defesa acostado documentos aos autos que apontam que a ré é gestante e usuária de entorpecentes, quando e sua abordagem não foram flagrada consumindo entorpecentes ou quem apetrechos para tanto, e a fim de que lhe seja reconhecida a falta ou prejuízo de sua capacidade, mister que ao tempo do fato a ré estivesse com seu discernimento comprometido pelo uso de entorpecentes e condição de usuária. A ré encontra-se em local desconhecido o que até mesmo impossibilitaria a designação de sua pericia e sem prejuízo, em fase de execução da pena poderá ser submetida a exame que comprove sua condição de dependente. Anoto por derradeiro que ré é reincidente específica. Superadas as preliminares arguidas, o pedido acusatório comporta parcial procedência. De fato, deve ser afastada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, pelas razões que passo a expor. A despeito da majorante em questão ter natureza objetiva e, portanto, dispensar a intenção do traficante de captar sua clientela junto aos frequentadores dos locais elencados no dispositivo legal supra citado, tem-se que, para não gerar responsabilidade penal objetiva, exige-se que haja concentração

de pessoas nas proximidades e adjacências daquele lugar para justificar a incidência da causa de aumento especial em tela. Ora, a ratio da norma visa exasperar a pena de pessoa que se aproveita da aglomeração de pessoas nas proximidades daquele local, facilitando a ocultação e evasão do traficante. In casu, como os fatos se deram por volta das 19h07, e o estabelecimento de recreação apontado a fls. 42/43 não tem qualquer foram de iluminação artificial, conforme documento de fls. 103. E, portanto, considerando que os fatos deram-se no período noturno, quando, obviamente, não havia iluminação solar, é evidente que o estabelecimento de recreação estava sem funcionamento e, conseqüentemente, não havia concentração de pessoas a justificar a incidência da causa de aumento em questão. A propósito, assim se posiciona a jurisprudência do C. STJ: RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. ART. 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/2006. INFRAÇÃO COMETIDA NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO EM UMA MADRUGADA DE DOMINGO. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DE UMA

AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS À ATIVIDADE CRIMINOSA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. 1. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006 tem natureza objetiva, não sendo necessária a efetiva comprovação de mercancia na respectiva entidade de ensino, ou mesmo de que o comércio visava a atingir os estudantes, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações do estabelecimento. A razão de ser da norma é punir de forma mais severa quem, por traficar nas dependências ou na proximidade de estabelecimento de ensino, tem maior proveito na difusão e no comércio de drogas em região de grande circulação de pessoas, expondo os frequentadores do local a um risco inerente à atividade criminosa da narcotraficância. 3. Na espécie, diante da prática do delito em dia e horário (domingo de madrugada) em que o estabelecimento de ensino não estava em funcionamento, de modo a facilitar a prática criminosa e a disseminação de drogas em área de maior aglomeração de pessoas, não há falar em incidência da majorante, pois ausente a ratio legis da norma em tela. 4. Recurso especial improvido. (REsp 1719792/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018). No mais, a pretensão acusatória merece ser acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de tráfico de entorpecentes, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada a tipicidade da conduta do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/11), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14 e 56), pelo auto de constatação preliminar (fls. 15 e 57/58), pelos laudos de exame químico-toxicológico (fls. 37/40 e 60/63) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. A ré, em sede policial (fls. 08), afirmou ser usuária de crack e que foi abordada somente com 5 pedras de crack. Desconhece as outras drogas e não estava vendendo entorpecentes. Analisando a autodefesa da acusada – colhida com máxima observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa – verifica-se que a ré admitiu a posse de parte dos entorpecentes, mas negou a destinação comercial desses. No entanto, essa alegação restou inverossímil, pois desprovida de lastro probatório. E porque, também, foi afastada pela prova produzida. De fato, a Guarda Civil Municipal Renata Rosa Rodrigues, ouvido em sede policial (fls. 07), narrou que, na data dos fatos, juntamente com seu parceiro, estavam em patrulhamento pelo Bairro Rosa Garcia 2. Então, foram acionados por um transeunte, o qual relatou que visualizou uma mulher alta, morena, de shorts vermelho e blusa escura, comercializando drogas na viela. O denunciante precisou que a mulher estava abaixando numa área verde do lado oposto da calçada onde se encontrava para pegar algo. As equipes se deslocaram até o local informado, onde avistaram uma mulher com as mesmas características da “denúncia”. Essa mulher, ao perceber a presença da viatura, mudou de comportamento e a colocou algo na boca. Ao ser abordada, foi pedido para ela retirar o que havia colocado na boca, oportunidade em que ela cuspiu 05 pedras de crack. A mulher foi identificada como sendo a ré e, em revista pessoal, foi localizado o valor de R\$ 22,00 em espécie. Ao averiguar o local onde MARCELA estava pegando algo, o cão Tom farejou 29 pedras de crack e 07 porções de cocaína tipo aricanduva. Em juízo, confirmou os fatos já relatados em solo policial, acresceu que as porções que estavam em sua boca eram idênticas aquelas encontradas do outro lado da rua pelo canil. Depois dessa ocorrência, receberam outras denuncia que noticiam que a ré continua no tráfico. Salvo engano a ré não trazia nenhum apetrecho para o uso da droga. Quando abordaram a ré não havia consumidor no local, mas as características da ré correspondiam exatamente com aqueles fornecidas pelo denunciante. No momento da abordagem a ré estava bastante agitada, o que se verifica em toda abordagem dela. Acredita que a ré permanece naquele local, nos barracos, grande parte do tempo. Convergindo em mesmo sentido, o também Guarda Civil Municipal Juceil Batista Rodrigues, em solo policial (fls. 08), corroborou integralmente de sua colega de corporação. Em juízo, disse que na data dos fatos estavam em patrulhamento pelo bairro quando foram abordados por um morador que disse que uma mulher morena, alta de short vermelha estaria vendendo drogas. Foram ao local apontado, identificaram a ré, ela colocou algo na boca e na abordagem cuspiu 5 porções de crack. A denuncia

falava que ela se dirigia a uma área verde em frente ao local em que estava. Com auxílio de cão farejador encontraram a droga na área verde. A ré disse que era usuária. A ré é conhecida dos meios policiais e não trazia consigo petrecho para uso da droga. A ré tem sido vista no mesmo local em que houve a abordagem e possivelmente realizando o tráfico. O denunciante tinha estatura mediana, com cerca de 1,75, moreno. A ré disse que era usuária. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos agentes públicos, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente o réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Nesse sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu, Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). Examinando o arcabouço probatório emergente dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ora, é inequívoco que a acusada trazia consigo e guardava entorpecentes, conforme: 1) os insuspeitos e coerentes depoimentos dos agentes de segurança, os quais relataram, em uníssono, terem apreendido parte dos entorpecentes com a acusada, os quais ela guardava na boca e cuspiu, e o restante no local onde ela estava abaixada; e 2) os laudos de exame químico-toxicológico (fls. 37/40 e 60/63), cujo teor atesta que as substâncias apreendidas eram entorpecentes. Também é indisfarçável a finalidade mercantil das drogas, a despeito da acusada não ter sido flagrada vendendo drogas. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo da ré de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 1) a quantidade de narcóticos apreendidos; 2) a ausência de instrumentos destinados ao consumo da droga; 3) a forma de acondicionamento da droga, em pequenas porções, forma típica da “venda a varejo” de entorpecentes; e 4) o comportamento suspeito da acusada, que, ao ver os guardas, tentou esconder as drogas em sua boca. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Dês. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal,

d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: “Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era “ponto de tráfico” e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de “cocaína” em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo “ependrof” de plástico incolor com tampa, contendo

pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da "cocaína" em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, aprendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de "cocaína" provoca o "enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação" (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654; RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudos de exames químicos-toxicológico a fls. 37/40 e 60/63) e demonstrado que a ré incorreu em verbo nuclear contido no artigo 33 da Lei 11343/06 - trazer consigo e guardar -, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Certo, portanto, que a ré perpetrou o fato típico narrado na exordial, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo a dosimetria da pena a ser lhe imposta. Observando as circunstâncias do artigo 59, caput, do Código Penal, verifico que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, na medida em que se cuida de ré reincidente. No entanto, como tal circunstância será apreciada em segunda fase, por ora, fixo sua pena-base no mínimo legal, isso é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Em segunda fase, presente a agravante de reincidência, que, aliás, é específica (Proc. nº 0000213-77.2017.8.26.0594, fls. 27), agravo sua pena na fração de 1/5, gerando a reprimenda legal de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a qual torno definitiva, à mingua de demais causas modificadoras da pena. Cabe ressaltar que, a despeito da admissão da posse das drogas, essa foi acompanhada de alegação de destinação para uso próprio, o que expressa confissão de crime diverso do qual a ré está sendo condenado. E, portanto, não se presta a caracterizar a atenuante de confissão (Súmula nº 630 do C. STJ). A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é inaplicável ao caso sub judice. De fato, a incidência dessa benesse legal reclama a presença simultânea de 04 requisitos subjetivos, a saber, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades delitivas e não integração a organização criminosa. In casu, tratando-se de ré reincidente, resta inviabilizada a concessão da benesse em questão. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal e, com fulcro no artigo 33, § 3º, c.c. art. 59, III, ambos do Código Penal, determino que o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, dada a reincidência, que, aliás, é específica, da acusada, que reclama a fixação de regime prisional mais severo para a contenção do ímpeto criminoso da ré. As mesmas motivações acima expostas impedem a concessão

dos benefícios do art. 44 do Código Penal. Por derradeiro, deixo de aplicar a regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), posto que a concessão desta medida dependa da análise de condições não exclusivamente objetivas, tal como o bom comportamento carcerário. Em assim sendo, não havendo nos autos informações sobre o cumprimento da pena, a viabilidade de concessão desta benesse restou prejudicada. Neste diapasão é o entendimento do E. TJSP. Vejamos: "No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena". (TJSP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n. 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, julgado em 04.06.2013). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para, afastando a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, condenar a ré MARCELA CRISTINA DE BRITO, devidamente qualificada nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Defiro apelo em liberdade da ré, eis que respondera solta ao processo e encontra-se gestante (documentos de fls. 105/111). Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento e arquivem-se os autos. Diante da condenação, fica ainda obrigado o réu a recolher custas de 100 (cem) UFESP's, na forma do art.4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03. Não lhe concedi os benefícios da Justiça Gratuita, pois a ré constituiu advogado (fls. 92), signo presuntivo de riqueza que revela a capacidade dela para suportar o ônus financeiro das custas processuais. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor referente às custas processuais e o total de pena de multa. Após, intime-se a ré para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo, considerando que os entorpecentes apreendidos já foram periciados, destruam-se as drogas na forma da lei. Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei nº 11.343/06, bem como do mandamento constitucional do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, ACOLHO o pedido confiscatório e DECRETO a perda do bem apreendido (R\$ 22,00 em dinheiro) em favor da União, apropriados os bens ao Funad (§1º do referido art. 63), pois comprovada sua proveniência criminosa". Pelo Defensor da ré foi manifestado o interesse em interpor recurso. Pela MM. Juíza de Direito foi dito: "Recebo o recurso interposto, saindo o Defensor, desde já, intimado a apresentar razões de recurso, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena de destituição e nomeação de novo Defensor. Após apresentadas as razões e com a vinda das contrarrazões remetam-se os autos à superior instância com as cautelas de praxe. Com o trânsito em julgado da condenação criminal, lance-se o nome do(a) réu no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se". ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA